

1500098-43.2022.8.26.0614

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Comarca: Tambaú

Foro: Foro de Tambaú

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... não são aptos a afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRIOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tambaú

Foro de Tambaú

Vara Única

Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500098-43.2022.8.26.0614 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500098-43.2022.8.26.0614

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2070419/2022 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 23589224 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 21/22/212 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2070419 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO GOMES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

LEONARDO GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia 14 de março de 2022, por volta das 12h00min., em uma via pública na Rua Sebastião Fabiano, Bairro Jardim Pontal das Pitãs, neste município e comarca de Tambaú-SP, o denunciado, mantinha em depósito, visando à mercancia ilícita, 73 pinos de cocaína (53.7) e 07 pedras de crack (0,7g.), tudo sem autorização.

Segundo o Ministério Público, "após denúncias anônimas, que vinculavam o denunciado, os policiais realizaram campanhas veladas para observá-lo à distância. Sendo assim, notou-se que LEONARDO entregava as drogas aos usuários, mas

primeiramente recebia o dinheiro e se descolava até um montante de areia, local onde pegava as substâncias ilícitas. Ao ser abordado, com ele nada foi encontrado além da quantia de R\$15,00 frutos do tráfico, mas no montante de areia, os policiais localizaram 66 pinos de cocaína, mais 07 pinos de cocaína e 07 pedras de crack".

Defesa preliminar apresentada (fls. 75/78).

A denúncia foi recebida em 15 de junho de 2022 (fls. 83/84).

O réu foi notificado. (fl. 104/105)

O réu foi citado (fl. 118).

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de outubro de 2022, às 15:00 (fl. 83/84).

Acusação e defesa apresentaram suas alegações finais por debates orais.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa, em seu turno, pleiteou a absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória e subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal.

É relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO MÉRITO

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa ao réu a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objetivo material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

DA PROVA

Há nos autos auto de prisão em flagrante (fls.01 e 02), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fl.10), auto de constatação preliminar (fls.11), laudo pericial (fls. 54/56 e 128/130), além da prova oral produzida. A testemunha César Augusto Seridônio, policial civil, disse que havia informação de que um indivíduo teria assumido a biqueira do Flávio Moreira. Disse que montou campana, visualizando Leonardo fazendo venda a um ou dois usuários. Disse que recebia algo e entregava algo. Disse que feita a abordagem de Leonardo, ele teria corrido, mas foi contido. Conta que observou que o réu escondia a droga em um monte de areia. No local encontrou 66 porções de cocaína e ao lado, em um outro monte de areia, um maço de cigarro com 7 pinos de cocaína e 7 pedras de crack. Evaldo Armando Antonialli, testemunha, policial civil, disse que tinha denúncia de que Leonardo teria assumido a biqueira. Disse que observou o réu servindo dois usuários. Disse que a autoridade policial determinou a abordagem. Conta que durante a observação observou onde a droga era escondida. No local em que ele escondia a droga, havia 73 porções individualizadas de cocaína, além de outras de crack. Conta que viu o réu se dirigir a um monte de areia, abaixando e pegando algo. Disse que estava há cerca de 25 metros com binóculo, demorando cerca de 15 minutos de campana.

Em seu interrogatório, o réu LEONARDO GOMES DOS SANTOS disse que não é verdadeira a alegação. Conta que estava com uma namorada, quando foi abordado. Disse que é de Pitangueiras e que nunca praticou o crime de tráfico de drogas.

DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls.01 e 02), auto de exibição e apreensão (fl.10), auto de constatação preliminar (fls.11), boletim de ocorrência (fls. 07/09), laudo pericial (fls. 54/56 e 128/130), além da prova oral produzida.

A autoria restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 02) e pela prova oral produzida em audiência.

Foram encontrados com o réu, R\$15,00 em moeda corrente, além de 73 eppendorfs contendo a substância cocaína e 07 pedras de crack, no local identificado nas campanas onde ele se deslocava para buscar as substâncias, visando a mercancia ilícita.

A quantidade de droga denota a traficância, ficando indene de dúvidas a finalidade para comercialização.

A movimentação do réu, fez com que não restassem dúvidas aos policiais civis a comercialização de drogas no local, além da possibilidade de identificação de que LEONARDO era quem entregava a droga e recebia o dinheiro dos usuários, e até mesmo o local onde as substâncias ficavam escondidas, sendo localizado na abordagem e com o réu tanto as substâncias entorpecentes, como uma quantia em dinheiro compatível com a venda.

Sendo assim, não restam dúvidas sobre a autoria do crime, levando em consideração também a quantidade de droga apreendida.

Outrossim, importa destacar que são verbos nucleares aptos a configurar a prática do delito, além da venda, oferecer, ter em depósito, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, e utilizar local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consentir que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Não há dúvida de que o depoimento dos policiais não é indene de dúvida ou impossíveis de serem inverídicos, contudo, no caso dos autos, são seguros e coincidentes, com riqueza de detalhes.

Encontra-se demonstrado portanto que o réu mantinha em depósito a droga, além de ter vendido o entorpecente. Portanto, configurada a prática do crime de tráfico de drogas.

Não há nestes autos elementos para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu, ou que seu relato não fosse digno de confiança.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer

testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. (TJSP APL 0015621-05.2004.8.26.0032 SP 0015621-05.2004.8.26.0032. Órgão Julgador 3ª Câmara de Direito Criminal; Publicação 08/03/2017; Julgamento 7 de Março de 2017; Relator Airton Vieira)

Observo que o Réu, contando com pouco mais de 18 anos, não responde por outros processos, é primário e possui bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Diante disto, e da pequena quantidade de droga traficada, é imperiosa a aplicação do §4º do art. 33, da Lei 11.343/06.

O réu foi preso portando a quantidade de 73 porções de cocaína, com peso aproximado de 53 gramas, e 7 porções de Crack, com peso aproximado de 1,91 gramas, o que justifica a aplicação do privilégio.

Anoto que conforme entendimento do STJ, eventuais atos infracionais praticados não são aptos a afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRIOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL. INCABÍVEL. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).
3. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).
4. Configura constrangimento ilegal a presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas pela simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a modulação da fração de redução de pena do tráfico privilegiado com considerações exclusivamente acerca desses fundamentos.
5. Os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração (EResp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção).
6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 762.383/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

O que justifica a aplicação do redutor de 1/3.

Advirto que não é possível determinar a fixação no regime inicial fechado independentemente do quantum da pena, em atenção ao TEMA 972 firmado em Repercussão Geral pelo STF.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Portanto, a fixação do regime dependerá do quantum da pena fixado e das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59, III, do Código Penal.

Ausentes causas de exclusão da ilicitude. O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas conduta, sendo-lhes exigível conduta diversa. Portanto, culpável.

A prova é certa, segura e não deixam dúvidas da condenação pela prática do delito de tráfico, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do código penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP, fazendo-a de forma individualizada.

A culpabilidade é normal a espécie. Não há maus antecedentes a serem valorados. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de droga não justificam maior exasperação. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Segunda etapa. Presente a atenuante genérica da menoridade relativa, contudo não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Diante disto, não há alteração na pena fixada inicialmente.

Terceira etapa. Reconheço a figura do tráfico privilegiado, porquanto seja o agente primário, possua bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas, tampouco integrar organização criminosa, considerando ainda a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, reduzo a pena em 1/3, nos termos do art. 33, §4, da Lei 11.343/06.

Torno definitiva a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 333 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: ABERTO

Diante do montante da pena arbitrada, não existindo outros elementos a serem ponderados na fixação do regime, determino seu cumprimento inicial no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, c, do CP, e do TEMA 972 firmado em Repercussão Geral pelo STF.

As circunstâncias judiciais indicam a POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritiva(s) de direito. A pena aplicada é inferior a quatro anos, não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, não é reincidente em crime doloso. Destarte, tratando-se de condenação superior a um ano, converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade e

limitação de final de semana.

Considerando a inexistência de local para cumprimento da medida nesta Comarca, o acusado deverá permanecer em sua residência, no período das 20:00 horas de sábado até as 06:00 horas de domingo, bem como das 20:00 horas de domingo até as 06:00 horas de segunda-feira, convertendo-se a limitação de final de semana em interdição temporária de direitos.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu LEONARDO GOMES DOS SANTOS pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, aplicando a pena 3 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 333 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana). Considerando o montante da condenação e o regime inicial fixado, mostra-se incompatível com a prisão preventiva, razão pela qual determino a expedição do alvará de soltura clausulado.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Caso ainda não tenha sido feito, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Se necessário, expeça certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento n° 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Tambaú, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA